

1524291-53.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524291-53.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524291-53.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273997/2021 - 08º D.P. BRAS, 20699234 - 08º D.P. BRAS, 5470/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2273997 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YOJANDRI JESUS RODRIGUES BARCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

YOJANDRI JESUS RODRIGUES BARCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 18h30, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), na Rua Joaquim Piza, nº 145, Liberdade, nesta cidade e comarca da Capital, ele trazia consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, (i) 09 (nove) porções de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como maconha, pesando 22,8 g (vinte e dois gramas e oito decigramas); (ii) 23 (vinte e três) porções de cocaína, pesando 16,6 g (dezesesseis gramas e seis decigramas); (iii) 18 (dezoito) porções de

cocaína na forma de crack, pesando 3,5 g (três gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 10,00 (dez reais) em espécie.

Determinei a notificação do acusado, fls. 82/83, o que ocorreu a fls. 89.

A defesa previa foi apresentada, fls. 93.

Recebida a denúncia, designei a data de hoje para a realização do audiência de instrução, debates e julgamento.

No dia de hoje foram ouvidos os policiais militares e o rpeu interrgado ao final. Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, com a condenação do acusado nos termos da denúncia, com a fixação da pena acima do mínimo diante da da diversidade de entorpecente. Condenação na agravante atinente a pandemia e impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena em razão de estar calaro que ele se dedica a pratica de crimes já que não há prova de traalho licito. A Defesa, por sua vez ,diante da ausência de provas, requereu a absolvição (art. 386, VII, do CPP). Em caso de condenação, quanto às penas, requereu: a) pena base: seja estabelecida no piso legal diante das favoráveis circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do CP);b) agravantes e atenuantes: Seja reconhecida a atenuante pela menoridade do agente (20 anos na data dos fatos, fls. 9); que seja afastada a agravante que consta da denúncia ante a ausência de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a pandemia de Covid19; c) causas de aumento e diminuição de pena: seja aplicada a minorante do art 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, visto que o réu é primário, possui bons antecedentes, e não a provas que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosas; d) regime inicial de cumprimento de pena: seja estabelecido o aberto, o que se pede diante do montante de pena aplicado, das favoráveis circunstâncias judiciais, da primariedade e do tempo de prisão provisória (desde 06/10/2021); e) substituição da pena: que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos, visto que o delito praticado não foi com violência contra a pessoa, a pena final do delito não ultrapassa o limite de 4 anos de reclusão; f) recurso em liberdade: por fim, seja deferido ao acusado o direito de recorrer da sentença em liberdade

É o relatório.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e dos laudos de constatação provisória (fls. 21 e 22/24), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substancia entorpecente

(fls.12/113), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Com efeito, o policial Adriano, ouvido sob o crivo do contraditório, declarou que se recorda do acusado referente a um trafico de entorpecente na rua Joaquim Pizza. O local já e conhecido como ponto de trafico. Ao passar em patrulhamento, o acusado começou a correr. Foram no encalço dele e então viu o momento em que ele tentou dispensr a pochete que usava. Ele entrou correnco por um corredor de moradia coletiva. Fizeram a abordagem e em seguida a varredura. Quanto aos fatos, por ser estrangeiro, em um primeiro momento ele admitiu que estava no trafico e como depois viu que seria preso, acabou por afirmar ser usuário. Ele negou residir no local. Não tem como afirmar se ele estava drogado. Ele aparentava ser morador de ruão entorpecente estava dividido, pronto para venda. Não chegou a vê-lo conversando com ninguém. Os fatos ocorreram no entardecer. Não se recorda de ter abordado o acusado anteriormente. Ele estava com a pochete nas mãos e quando vialuzou a viatura, correu. Com ele apreendeu R\$ 10,00.

Já o policial José Geraldo reconheceu o acusado de trafico de entorpecentes. A equipe estava em patrulhamento e o local já era conhecido por trafico. O acusado,

ao visualizar a equipe saiu correndo em direção a uma local de habitação coletiva. Ele correu e tentou se livrar de algo. Ele foi detido e após a varredura localizamos a bolsa. Dentro da pochete encontrou porções de cocaína, maconha e crack já fracionadas para venda. R\$ 10,00 estavam na posse dele. Os fatos ocorreram ao entardecer. Já estava ficando escuro. No momento da abordagem ele assumiu que a droga era dele e que estava na prática ilícita mas depois voltou atrás e disse ser usuário. Não se recorda se ele declarou ser morador dali. Não se recorda do causado mas patrulha bem o local. Na verdade, ao ser visualizado, ele estava com algo nas mãos e o que foi localizado posteriormente era bem parecido com o que foi apreendido.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Além de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos a versão do acusado obtida em juízo, a qual considero inverossímil, vejamos. Yojandri declarou que tem 21 anos de idade. É venezuelano e mora no Brasil há 4 anos. Trabalha em uma hamburgueria, na Zona Norte, Rua Henrique Fortelino, 344. Tem registro em carteira. Trabalha das 9 as 16 hs. Reside no endereço mencionados no BO, fl. 9 com a esposa. Nunca foi processado anteriormente. Neste dia estava de folga. Foi comprar uma porção de maconha e quando estava comprando, a polícia chegou. Não estava com bolsa na mão. Não estava com a bolsa. O local é longe da sua casa, cerca de 20 minutos. Foi de ônibus comprar a droga. Pegou o ônibus "liberdade". Já comprou drogas no local anteriormente. Não sabe o nome do traficante, era a segunda vez que ia comprar a droga. Os outros correram, inclusive o traficante. Ele portava uma bolsa grande que não se trata de uma pochete. Como se percebe sua versão não pode ser aceita por esse juízo já que fantasiosa. O intuito é livrar-se de sua responsabilidade criminal e para tanto aduz ter sido forjado pelos policiais que sequer o conheciam e que motivo algum teriam para incriminá-lo falsamente.

Ele não comprovou trabalho lícito e muito menos o que estava fazendo naquele local, distante de sua residência.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena

base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante referente a calamidade publica eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua pratica. Não há prova de nexa causal. De igual forma, a menoridade relativa não será utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do trafico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls.29/31. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa apenas porque estivesse na posse de 26,3 de entorpecente, ainda que em sua forma variada. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstancias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a pratica delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO:INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno YOJANDRI JESUS RODRIGUES BARCO, nascido em 12/09/2001, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006,

impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 12/13). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Isento de custas.

Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA